



Cramdown



Concepto

- Dasso: “el rescate de la empresa implica la intervención de terceros interesados en comprar la empresa, operatoria que se lleva a cabo mediante la inscripción de interesados, que deben lograr un acuerdo con los acreedores y así obtener el derecho a la transferencia de la totalidad del paquete accionario”
- Vitolo: “se establece la posibilidad de que acreedores o terceros interesados que se inscriban en un registro oportunamente abierto por el juzgado interviniente, puedan ofrecer acuerdo a los otros acreedores. En el caso de que dicho acuerdo resulte aprobado por las mayorías exigidas por la ley, quien haya formulado la propuesta deberá adquirir las cuotas sociales o acciones que representen el 100% del capital de la sociedad concursada, por su valor patrimonial reducido en la misma proporción en que fueran reducidos los montos definitivos de los créditos de titularidad de los acreedores comprendidos en el acuerdo, calculados a valor presente. se permite el rescate de la unidad productiva y, a su vez, se impone un principio de equidad, en virtud del cual los titulares del capital social de la sociedad concursada (socios o accionistas) compartan el sacrificio común de los acreedores”

Exclusiones

- pequeños concursos, los cuales están definidos en el art. 288 como aquellos en los que indistintamente se da alguna de las siguientes hipótesis: i) pasivo inferior a 300 smvm ii) no más de veinte acreedores quirografarios; iii) no más de veinte trabajadores en relación de dependencia

CONSTITUCIONALIDAD DEL SALVATAJE

- alguna doctrina cuestionó la constitucionalidad del sistema de salvataje. Se argumentó que se violentaba el derecho de propiedad de los socios de la empresa en crisis al establecerse la transferencia forzosa de sus participaciones, ya que quien se encontraba en concurso era la sociedad y no los socios. Por otra parte, se sostuvo la injusticia que se sigue de aplicar el instituto a los socios que votaron en minoría cuando se resolvió el sometimiento a la alternativa concursal
- la Cámara Nacional de Comercio, sala E, sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 24.522 requiere que el peticionante demuestre y acredite fehacientemente en la causa el perjuicio que le origina la aplicación del sistema en controversia. A ello se agrega, además, que la eventual aplicación del art. 48 sólo afectaría a los accionistas de la sociedad, pero no a esta última, en virtud del cual el agravio tampoco es atendible en tanto se le invoca el interés de terceros cuya representación no se inviste.

NATURALEZA JURÍDICA

- Dice Mosso : “la empresa sigue siendo la misma, la sociedad que la explota sigue siendo la misma, todo lo que ocurre es el "reemplazo de los accionistas" de la sociedad en concurso, sociedad que, inmodificada, explota una empresa igualmente inmodificada”
- los acreedores seguirán teniendo el mismo deudor, pues no hay novación subjetiva, ya que es la misma sociedad concursada la que adeuda
- el tercero interesado que, obteniendo las conformidades, adquiera la titularidad de las cuotas sociales, reemplaza a los anteriores dueños del capital en la conducción de la sociedad concursada, pero no "toma" las deudas sociales anteriores como personales, porque seguirá existiendo separación en cuanto a la personalidad con el ente societario.

LEGITIMADOS PASIVOS

- el texto legal sigue legitimando solamente a las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas y aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte
- admite un número de sujetos habilitados para obtener el procedimiento de salvataje

SUJETOS COMPRENDIDOS

- Sociedades comerciales - sólo están habilitadas para acceder al salvataje las SRL, las SA, las cooperativas y las sociedades donde el Estado nacional provincial o municipal sea parte. En relación con las sociedades comerciales, la ley habilita solamente a aquellos tipos sociales donde los socios limitan su responsabilidad
- Las cooperativas - El art. 162 del CCCN, hoy establece:
"Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto"
- Sociedades del Estado
- Asociaciones mutuales

SUJETOS EXCLUIDOS

- i) personas físicas, a despecho del nivel de la organización empresarial que desarrollan; ii) otras personas de existencia ideal que no sean las expresamente habilitadas por el art. 48; iii) personas jurídicas que no pueden ser sujeto de concursos preventivos, como son las aseguradoras o entidades financieras; iv) cualquier clase de persona, aun las mencionadas en el encabezamiento del art. 48, cuando se trate de pequeños concursos

Los pequeños concursos

se mantiene la limitación contenida en el art. 289 que impide su acceso al salvataje, todo lo cual ha motivado la crítica de la doctrina, puntualizándose que el criterio empleado por el art. 288 de la ley 24.522 para determinar la viabilidad del salvataje no se corresponde con la noción de utilidad empresarial, que es la que debiera primar como criterio definitorio de esta alternativa de reorganización

La doctrina da cuenta de algún caso jurisprudencial donde se decidió la apertura del salvataje en el pequeño concurso, condicionado a la ratificación de los socios en asamblea extraordinaria, ya que la exclusión del salvataje no es una cuestión que afecte al orden público

algún otro fallo declaró la inconstitucionalidad del art. 289 para habilitar el salvataje de un pequeño concurso

Ante esta situación doctrinaria y jurisprudencial, Di Tullio, Macagno y Chiavassa(280) sostienen que no debe descartarse la posibilidad de una aplicación pretoriana del instituto a los pequeños concursos.

En rigor, la jurisprudencia, aun antes de la sanción de la originaria ley 24.522, ya había tenido casos en los cuales la empresa concursada vendía su paquete accionario y quien obtenía las conformidades concordatarias era la nueva conducción societaria, viabilizando el mantenimiento de la explotación empresarial.

Esto es lo que sucede en el denominado "cramdown a la criolla".

REGISTRO DE INTERESADOS

el juez tiene un plazo de dos días para disponer la apertura de un registro en el expediente para que, dentro del término de cinco días, se inscriban los acreedores y terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital de la concursada, a efectos de formular propuestas de acuerdo preventivo

la finalidad del instituto, que es la transferencia societaria, aun cuando no pueda olvidarse que constituye un negocio indirecto para adquirir el control y manejo empresario.

Este segundo período de negociación tiene como finalidad que otras personas distintas de la concursada adquieran, por vía de negociación, el capital social o se les reconozca el derecho de su transferencia, siempre que acuerden con los acreedores el modo de satisfacción del pasivo con las mayorías del art. 45, a saber, la mayoría absoluta de acreedores verificados y admisibles que representan las dos terceras partes del pasivo quirografario.

art. 48, inc. 4º, al puntualizar que el deudor "recobra" la posibilidad de procurar adhesiones a su anterior propuesta o a las nuevas que formulase, en los mismos plazos y compitiendo sin ninguna preferencia con el resto de los interesados oferentes.

INEXISTENCIA DE INSCRIPTOS: QUIEBRA



I TRANSCURRIDO EL PLAZO PREVISTO EN EL INC.
1º NO HUBIERA NINGÚN INSCRIPTO, EL JUEZ
DECLARARÁ LA QUIEBRA.



LO DICHO PONE DE RELIEVE QUE LA
CONCURRENCIA DE LA DEUDORA A ESTA
SEGUNDA VUELTA DEPENDE SIEMPRE DE QUE
EXISTAN TERCEROS INSCRIPTOS, PUES SU
AUSENCIA OBLIGA A DECLARAR LA QUIEBRA

VALUACIÓN DE LAS CUOTAS O ACCIONES

- existiendo inscriptos, el juez debe designar al evaluador que refiere el art. 262, su función es asignar un valor a las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada a fin de que el juez tenga fundamento técnico para resolver sobre dicha valuación
- en caso de que el tercero oferente hubiera obtenido el acuerdo de los acreedores, el evaluador debe dictaminar sobre el valor presente del pasivo quirografario, con el objeto de que las participaciones societarias **tengan la misma merma que los acreedores**, de conformidad a las pautas enunciadas por el art. 48, inc. 7º.
- pueden actuar como evaluadores los bancos de inversión, las entidades financieras autorizadas por el BCRA y los estudios de auditoría con más de diez años de antigüedad

La valuación de las participaciones societarias

- debe establecer el valor real de mercado ponderando: i) el informe del síndico, art. 39, incs. 2º y 3º; ii) altas, bajas y modificaciones sustanciales de los activos; iii) incidencia de los pasivos posconcursoales
- cuando la nueva ley se refiere al "real valor de mercado", intenta determinar el valor de transacción al cual el activo puede cambiar de mano entre un probable comprador y un probable vendedor, teniendo conocimiento razonable de todos los factores relevantes a la fecha de la valuación.
- Los factores que se tienen en cuenta para determinar el flujo de fondos y la correcta valuación de la empresa, además de los beneficios futuros, lo constituyen los bienes incorporables, como la propiedad industrial, fórmulas químicas, procesos técnicos, marcas de fábricas, patentes, propiedad literaria y artística, y demás intangibles. A esos fines resulta necesario ponderar la posición de la empresa en el mercado, la calidad de la mercadería o el servicio, el trato a los clientes, las buenas relaciones con los trabajadores, la confianza en el buen desempeño gerencial, entre otros elementos.
- En una palabra, sólo una adecuada auditoría contable y un serio análisis de gestión empresarial puede conducir a una valuación seria que se ajuste al "real valor de mercado"
- El evaluador tiene un plazo de treinta días hábiles para presentar su informe al juzgado, y éste puede ser observado dentro de cinco días

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

- la resolución judicial que disponga el nombramiento del evaluador también debe contener la decisión sobre el tema de la administración. En efecto, la sociedad deudora ha fracasado en el período de exclusividad, y si bien no se ha declarado la quiebra, surge la duda sobre si debe mantenerse en la administración (art. 15 y 16, LCQ).
- En el caso "Pedro y José Martín s/concurso preventivo"(290) se resolvió que se debe mantener a los administradores de la concursada, acentuando la función de vigilancia por parte de la sindicatura y del comité de acreedores
- Muchas veces los administradores no aseguran el correcto funcionamiento empresarial y que se hace necesaria la separación de los mismos y la designación de un administrador ad hoc(art. 17, LCQ)(291). Esta situación fue analizada en la causa "Ferroviaria SA s/concurso preventivo"(292) por el juez mendocino Fraga, en donde, tomando en cuenta los antecedentes del órgano ejecutivo, se designó un coadministrador y se constituyó un comité de crisis de acreedores

NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO PREVENTIVO

- El plazo es de veinte días hábiles para que los acreedores destinatarios de la o las propuestas puedan prestar su conformidad a una, a varias o a todas ellas. También está prevista la celebración de una audiencia informativa, cinco días antes de vencido el plazo para negociar las propuestas de acuerdo
- El derecho de la deudora a participar en el período de concurrencia es consecuencia de la previa inscripción de terceros interesados y no implica la posibilidad de que la sociedad se inscriba originariamente en el registro.
- Las mayorías son iguales a las que rigen durante el período de exclusividad, de conformidad a los arts. 43 y 45 del estatuto concursal

CONCORDATO DE LA SOCIEDAD CONCURSADA

- si el primero que hubiera obtenido las conformidades de los acreedores es la **deudora concursada**, se aplican las reglas previstas en el período de exclusividad (arts. 49 y ss.).
- Si quien hubiese demostrado la obtención de las mayorías es un tercero, debe transitarse la etapa de la adquisición del paquete accionario, de conformidad al inc. 7º del art. 48.
- Como lo puntualiza Dasso con toda claridad, el nuevo sistema sigue privilegiando una **carrera contra el tiempo**, en lugar de priorizar la oferta que contuviera "el mejor precio", que es la condición justificante desde el punto de vista constitucional de la transferencia forzosa que implica el cramdown

ACUERDO OBTENIDO POR UN TERCERO

- hay que proceder a una nueva valuación, detrayendo del valor de las participaciones societarias el mismo porcentaje que hayan "sacrificado los acreedores en el acuerdo con el tercero cramdista".
- Se trata de que los socios soporten igual merma que los acreedores
- exige un nuevo dictamen del evaluador que ajuste el pasivo quirografario a valor presente y determine en qué proporción se reduce de conformidad al acuerdo obtenido por el tercero
- El valor presente del pasivo quirografario debe cotejarse con el valor atribuido en la oportunidad de la valuación de las participaciones societarias, y de dicha comparación surgirá la proporción en que debe reducirse el valor de las cuotas o acciones representativas del capital social de la concursada. En esta línea, si como resultado de la valuación las cuotas o acciones representativas del capital carecieran de valor positivo, el tercero adquiere el derecho a que se le transfiera su titularidad juntamente con la homologación del acuerdo.
- atento a la falta de valor de las cuotas o acciones sociales, el tercero que acordó con los acreedores de la concursada nada debe pagar o negociar con los socios. Por el contrario, si el valor fijado judicialmente fuera positivo, corresponde establecer una quita comparativa o en la misma proporción en la que se reduce el pasivo quirografario a valor presente como consecuencia del acuerdo alcanzado por el tercero.

ADQUISICIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO

- Una vez definido judicialmente el valor de las participaciones societarias, con la correspondiente merma establecida en el inc. 7º, b) del art. 48, para que tanto los socios como los acreedores estén en igualdad de tratamiento el tercero puede seguir dos caminos:
- i) manifestar que pagará el importe respectivo a los socios depositando el 25% del precio en garantía y a cuenta del saldo que deberá efectivizar dentro de los diez días posteriores a la homologación judicial;
- ii) la ley le concede un plazo de veinte días hábiles judiciales durante los cuales el tercero puede acordar con los socios el pago de un valor inferior al establecido por el juez. A estos fines deberá obtener la conformidad de los socios o accionistas que representen las dos terceras partes del capital social de la concursada. Como se ve, las conformidades no implican una asamblea societaria, sino simplemente las conformidades individuales de los socios que alcancen el porcentaje de capital requerido.

Ejemplo

Valor inicial de acciones: \$ 140

Valor Pasivo (inciso 3): \$ 400

Valor Presente del Pasivo quirografario
con el acuerdo: \$ 200

Proporción del sacrificio (c / b): 0,50
(50%)

Valor reducido de las acciones: \$ 70 (\$
140/2)